

0003039-13.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... ressaltando que para configuração do crime de tráfico de drogas não é necessário que o acusado seja flagrado comercializando drogas, bastando a prática de quaisquer dos verbos constantes do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, veja-se o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESPECIAL FIM DE AGIR. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0003039-13.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003039-13.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1741/2021 - CENTRAL DE POLÍCIA

JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP, 178/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ourinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

DIOGO DE OLIVEIRA, qualificado na fl.19, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque segundo a denúncia no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 12h12, na Rua Gaspar Ricardo, nº 1000, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Ourinhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 29 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 3,8 g e 01 porção bruta de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 29,58 g, conforme laudo de constatação provisória das drogas acostado a fls. 14/16, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia, com rol testemunhal (fls. 108/109).

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 pela decisão proferida às fls. 148/151, após o que o réu foi regularmente citado (fls. 191).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação Edmilson Rodrigues e Romero Lucas Franco, a testemunha defensiva Maria Fernanda Ferraz e foi tomado o interrogatório do réu Diogo de Oliveira, seguindo-se pelos debates orais, nos quais o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A Defesa, por seu turno, levantou preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da amásia do réu como testemunha de defesa, a qual estava no local da abordagem e presenciou o ocorrido. No mérito, pugnou pela absolvição do réu pela nulidade processual e, subsidiariamente postulou a desclassificação da imputação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Preliminarmente a Defesa do réu alega cerceamento ao direito de defesa, uma vez que foi indeferido a oitiva da esposa dele, a qual, no entanto, estava presente no local dos fatos e presenciou a abordagem policial.

A decisão que indeferiu a inquirição da informante Monique Cardoso de Azevedo consta no Termo de Audiência e esta assim fundamentada (fl. 206/207): "Indefiro a oitiva da testemunha defensiva Monique Cardoso de Azevedo, haja vista tratar-se de amásia do acusado, por ela mesmo declarado viver em união estável quando questionada sobre a relação de parentesco com o réu. Vale anotar que cabe ao julgador perquirir acerca da pertinência e viabilidade da prova, o que no caso mostra-se desnecessária, uma vez que a testemunha seria ouvida na qualidade de informante e possui claro interesse no deslinde da ação penal. Nesse sentido, o TJSP: Apelação da Defesa – tráfico de drogas – preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva do menor – cabe ao Juízo analisar a necessidade da oitiva de testemunha, como prova ao deslinde da ação – ausência de prejuízo – preliminar afastada – materialidade e autoria comprovadas – denúncia anônima anterior, além da apreensão de 25 "ependorfs" contendo cocaína, com peso aproximado de 19 gramas, 41 invólucros de maconha, com peso aproximado de 90 gramas, 123 porções de "crack", com peso aproximado de 39,5 gramas, além da quantia de R\$ 5,00, com o adolescente – apreensão também de uma quantia em dinheiro em poder do réu Fernando, cuja origem lícita não foi comprovada -- causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas – comprovado o envolvimento do adolescente na prática do comércio ilegal de entorpecente – desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas inviável – demonstrada a finalidade de entrega a terceiros – impossibilidade também da desclassificação para a conduta descrita no artigo 37 da Lei de Drogas – hipótese de colaboração, a título de informante, não configurada – condenações mantidas – penas fixadas no mínimo legal, a despeito da quantidade e da natureza deletéria da droga, assim mantidas, ante o conformismo do representante do Ministério Público – réu Fernando reincidente, o que justifica o aumento da pena na fração de 1/6 – acréscimo das penas na fração de 1/6 diante da causa de aumento – redutor do artigo 33 §4º – inapropriado à hipótese dos autos, em que a prova colhida bem demonstra a dedicação ininterrupta dos réus ao comércio ilegal de entorpecente, além da reincidência do réu Fernando – razoável quantidade e variedade de droga apreendida – não demonstrado o exercício de atividade lícita – condenações que devem ser cumpridas em regime inicial fechado – disposição legal expressa no art. 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/1990 – substituição da pena privativa por restritiva de direitos – mercê incompatível com delito de singular gravidade – recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 0067940-07.2015.8.26.0050; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018). Também o TJSP: APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - Violação ao art. 226 do CPP - Inocorrência - Mera recomendação - Ausência de prejuízo - Formalismo exagerado - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de convicção colhidos - Indeferimento da oitiva de testemunhas - Não ocorrência - Preclusão - Desnecessidade - Pessoas que, por serem familiares do réu, seriam ouvidas como informantes, e não testemunhas - MÉRITO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada - Palavras da vítima firmes e seguras - Validade -

Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública - Ausência de interesse em prejudicar o acusado - Quadro probatório suficiente para a condenação - Pena que não comporta alteração - Regime fechado mantido - Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500229-58.2020.8.26.0397; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021)". Desta forma, o indeferimento da almejada inquirição da informante foi devidamente justificado e fundamentado.

Outrossim, lembra-se que o ordenamento jurídico adotou o Sistema da Instrumentalidade das Formas, em substituição ao da Legalidade das Formas, o que significa que não basta que o ato esteja em desconformidade com a lei, pois, também se exige que se demonstre o prejuízo à parte.

Conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", sendo importante ressaltar, ademais, que o artigo 566 do mesmo código dispõe que: "não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa".

No caso, observa-se que a Defesa não comprovou ter havido prejuízo à Defesa do réu, até porque a testemunha Maria Fernanda Ferraz, que estava junto com a esposa do réu no local da abordagem, foi ouvida como testemunha de Defesa durante a instrução processual, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Por tais fundamentos rejeito a preliminar e passo a análise de mérito.

Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado o crime de tráfico de drogas, a qual merece procedência haja vista que o acervo probatório reunido nos autos corrobora a versão acusatória.

Isso porque, a materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09; auto de exibição e apreensão de fls. 10/13, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 14/40 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 131/135.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Vejamos.

O acusado Diogo de Oliveira negou a prática do tráfico de drogas tanto em solo policial como em juízo, afirmando que na ocasião dos fatos havia acabado de adquirir cinco pedras de crack para consumo pessoal, as quais tentou engolir ao perceber a iminência da abordagem policial, no entanto não conseguiu, razão pela qual tentou dispensá-las jogando-as sobre um muro, no entanto as drogas acabaram batendo no muro e caindo ao solo, motivo pelo qual decidiu fugir com medo de ser preso. Disse que quando foi abordado não estava na posse de qualquer porção de crack, possuía apenas um cigarro de "mesclado", o qual o policial encontrou em sua posse, porém entregou para a esposa do depoente, dizendo que ela deveria fumar aquilo para se acalmar. Disse que após ser detido, os policiais retornaram até o local onde os entorpecentes haviam caído e lá observaram que havia vários usuários tentando pegar as drogas, as quais, no entanto foram localizadas e apreendidas pelos policiais. Informou que o dinheiro que está apreendido nos autos estava com sua amásia e que ela tentou entregar para o interrogando na DEPOL para ele comprar coisas na cadeia pública, no entanto os policiais da escolta não deixaram e acabaram entregando à Autoridade Policial.

Por sua vez, os policiais militares Edmilson Rodrigues e Romero Lucas Franco informaram, sob o crivo do contraditório, que na ocasião dos fatos estavam realizando patrulhamento tático pela Vila Marcante, em local conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas, ocasião em que avistaram uma roda de pessoas, dentre elas o réu, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, fechou uma das mãos e saiu caminhando, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem. Nesse momento perceberam que o réu tentou dispensar o que tinha nas mãos, no entanto o objeto bateu em um muro alto e acabou caindo no chão, tendo os depoentes notado que se tratava de diversas porções de droga. Na sequência os milicianos saíram no encalço do réu, o qual foi alcançado quando já estava no canteiro central da Rodovia, com auxílio de outro policial, oportunidade em que foi

abordado e revistado. Na oportunidade foi encontrado escondido dentro da cueca dele uma porção bruta de crack e a quantia de R\$164,00 em notas diversas. Nesse momento foi dado ordem de prisão ao réu e os milicianos retornaram até o local onde o réu havia dispensado algo e lá encontraram 29 pedras de crack. Ressaltaram que o réu, logo que foi abordado já disse "perdeu perdeu" e acabou confessando a prática do tráfico, pedindo para que os policiais entregassem o dinheiro encontrado com ele para a esposa, a qual estava grávida. Salientaram que no local em que o réu dispensou as drogas havia vários usuários tentando pegar as porções caídas ao solo, bem como salientaram que a esposa do réu, juntamente com outra mulher gritavam para o réu fugir, enquanto ele estava sendo perseguido. Finalmente ressaltaram que ele é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, inclusive já havia sido abordado em outra oportunidade.

A testemunha de defesa Maria Fernanda Ferraz informou que na ocasião dos fatos estava com o réu e a esposa dele pela Vila Marcante quando os policiais se aproximaram, oportunidade em que o réu tentou esconder cinco porções de crack que estavam com ele em sua boca, no entanto não conseguiu engolir a droga e acabou jogando o entorpecente na rua, após o que saiu correndo da polícia, foi perseguido e alcançado por outro policial. Na sequência o réu foi revistado, porém os policiais não encontraram nenhuma porção de crack com ele, apenas um baseado que estava na orelha dele. Ato contínuo os policiais retornaram até o local onde o réu dispensou a droga e lá encontrou apenas 05 (cinco) porções, porém ressaltou que em nenhum momento viu quantas porções o réu tinha em mãos, tendo tomado conhecimento da quantia através da amásia dele. Ressaltou ser usuária de drogas e disse que estava no local para consumir drogas junto com eles. Finalmente informou que o réu nunca teve qualquer desentendimento com policiais militares.

Estes são, em síntese, os elementos probatórios reunidos nos autos.

Como se vê, muito embora o réu tenha negado a prática do crime, admitindo apenas a propriedade de cinco porções de crack, as quais teria acabado de comprar para consumo pessoal, as declarações dos policiais militares Edmilson Rodrigues e Romero Lucas Franco, harmônicas e coesas entre si, revelaram que na ocasião dos fatos o réu foi visto em local publicamente conhecido pela existência do tráfico de drogas, oportunidade em que ele, ao notar a aproximação da equipe policial, demonstrou comportamento suspeito e, ao perceber que seria abordado, dispensou algo que tinha nas mãos e saiu correndo. Ocorre que o objeto dispensado pelo réu acabou batendo contra um muro alto e caiu no chão, revelando que se tratava de diversas porções de droga. Na sequência, o réu foi perseguido, capturado e submetido a revista pessoal, a qual resultou na localização de uma porção bruta de crack e a quantia de R\$164,00 em notas diversas, que estavam escondidas dentro da cueca dele. Já no local onde o réu dispensou as drogas foram localizadas outras 29 porções individuais de crack, as quais foram recolhidas, apreendidas e apresentadas à Autoridade Policial.

Vale ressaltar que não se vislumbrou, em qualquer momento do processado, fatos que pudessem colocar em dúvida a ação policial, ou mesmo desabonassem os depoimentos prestados por essas testemunhas.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age acionamento ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos [...]"(HC n. 74.608-0, rel. Minc Celso de Mello)

Nesse sentido também destaca decisão de lavra da Corte Bandeirante:

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que

concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJSP; Apelação Criminal 0013199-80.2013.8.26.0278; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018).

Ademais, nota-se que a versão do réu, no sentido de que parte da droga foi forjada pelos policiais não restou minimamente comprovada nos autos, não tendo sido sequer demonstrada a existência de desavença ou desentendimento anterior entre o réu e os policiais militares que pudesse justificar a falsa acusação.

Dissertando acerca do ônus da prova no processo penal, a doutrina do jurista Renato Brasileiro de Lima, em Manual de Processo Penal, 2015, p. 596/597 nos ensina:

“De outro lado, valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, inciso II - art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova. De modo semelhante, se o acusado alegar que houve renúncia tácita ao direito de queixa, caberá a ele o ônus da prova quanto à referida causa extintiva da punibilidade (CP, art. I 07, inciso V). Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um alibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação[...]

Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova : para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável ; para a defesa, basta criar um estado de dúvida”.

De acordo com esse entendimento, verifico que a Defesa não apresentou elementos mínimos para comprovar o alibi alegado ou mesmo para incutir dúvidas na convicção dessa magistrada quanto à propriedade das drogas atribuídas ao réu.

Não fosse o bastante, nota-se pelas fotografias que acompanham o Laudo Pericial de fls. 131/135 que as porções de droga apreendidas nos autos apresentam características de tamanho e cor semelhantes, bem como observa-se a ausência de embalagens em todas elas. Tais semelhanças revelam, em princípio, a origem comum de todas elas e, por consequência, enfraquecem a alegação do réu no sentido de que apenas cinco porções lhe pertenciam.

Outrossim, destaca-se que tanta as testemunhas de acusação como a de defesa ressaltaram que enquanto o réu estava sendo perseguido e abordado pelos policiais, vários usuários de droga se aproximaram do local onde as porções de crack foram jogadas no intuito de se apropriar de algumas delas. Portanto, é bem possível que parte do entorpecente dispensado pelo réu tenha sido subtraído por usuários na ocasião.

Logo, diante da fragilidade da versão do réu e da ausência de elementos probatórios aptos a corroborá-la, não há como privilegiá-la em detrimento da acusatória, a qual, como visto, restou sobejamente comprovada nos autos.

Desta forma, restando suficientemente demonstrado que toda droga pertencia ao acusado, passo a análise de sua destinação, ressaltando que para configuração do crime de tráfico de drogas não é necessário que o acusado seja flagrado comercializando drogas, bastando a prática de quaisquer dos verbos constantes do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, veja-se o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESPECIAL FIM DE AGIR.

PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6.368/76, não se exige a presença do especial fim de agir consistente na finalidade de comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas estabelecidas no dispositivo. 2. De outro lado, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito descrito no artigo 16 da Lei de Tóxicos somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo uso própria da substância, elementar subjetivo especial do tipo. 3. Recurso especial conhecido e provido (REsp. 812.950/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 29/05/2008).

No caso, foram apreendidas 3,8 gramas de crack, em 29 porções individuais, e 01 porção bruta da mesma substância ilícita com peso líquido de 29,58g, quantia que, por si só, constitui forte indício da traficância, haja vista que o cotidiano forense tem revelado que usualmente a porção individual do crack equivale a cerca de 0,1 grama (STF HC nº 114.390/RS 1ª Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.), o que revela que a porção bruta seria suficiente para produzir mais de 200 porções individuais.

Além disso, como visto, parte da droga já se encontrava repartida em porções menores, prontas, portanto, para serem comercializadas.

Soma-se a este indício que, além do entorpecente, foi apreendida a quantia de R\$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) em dinheiro na posse do acusado, cuja origem não restou suficientemente esclarecida, sendo possível concluir, diante do contexto dos autos, que o montante foi obtido através da venda de drogas.

Todas estas circunstâncias da prisão em flagrante, aliado ao conjunto probatório consubstanciado principalmente nos depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, comprovam, de forma inequívoca, que o acusado se dedicava à nefasta mercancia de drogas.

Não havendo qualquer outra consideração a ser feita, passo a dosimetria e à fixação da pena, atenta às diretrizes fixadas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Nessa esteira, verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu registra antecedentes criminais que consubstanciem maus antecedentes (fls. 118/120), porquanto ostenta duas condenações criminais que não são aptas a gerar reincidência. Por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. Já quanto às circunstâncias e consequências do crime, analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, anoto que a natureza da droga apreendida com o réu tem alto poder viciante, o que deve ser sopesado em seu desfavor. Nesses termos, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base acima do patamar mínimo legal em 1/4 (um quarto), isto é, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes. Lado outro, incide a agravante da reincidência, que é específica, conforme aponta a certidão de fls. 118/120.

Aqui, cedio que o Código Penal não estabelece limite mínimo e máximo para o aumento da reprimenda em casos de circunstâncias agravantes. Por outro lado, esta julgadora não se escusa do entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há diferenciação entre a reincidência específica ou genérica no tocante à fração a ser aplicada em decorrência desta agravante, havendo consenso do montante de um sexto seja qual for a hipótese.

Todavia, no caso em apreço estão presentes circunstâncias concretas que determinam o maior agravamento. De acordo com a folha de antecedentes, observa-se que o denunciado sequer cumpriu integralmente a condenação anterior e novamente veio a se envolver com crime de mesma natureza, tornando maior o grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido destaco alguns julgados da Corte Bandeirante. Vejamos:

“Reincidente específico em relação ao tráfico de drogas, daí porque justificável o aumento na fração de 1/4, dada a maior reprovabilidade” (TJSP; Apelação Criminal

1501900-52.2019.8.26.0559; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

“Em que pese a lei não defina o percentual a ser adotado, esta Câmara vem reiteradamente optando por 1/5” (TJSP; Apelação Criminal 1502791-90.2020.8.26.0542; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Destarte, tendo como norte os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, agravo em 1/5 (um quinto) a pena anteriormente fixada, a qual passa ao montante 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Finalmente, tratando-se de réu reincidente específico, inviável a aplicação do benefício disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. Neste sentido, “Na etapa derradeira, impossível o acolhimento da pretensão da defesa, tendo em vista a reincidência do paciente, a qual afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (HC 395.081/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Inviável se mostra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por ser o réu réu reincidente específico (artigo 44, inciso II, § 3º, do CP) e porque a pena suplantou o teto legal de 04 (quatro) anos, (artigo 44, caput, CP).

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime hediondo, a lei impõe a fixação no fechado. Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Nesses termos, observa-se que o réu encontra-se encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme art. 112, inciso V da LEP, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra DIOGO DE OLIVEIRA, qualificado na fl.19, para CONDENARLO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Demonstrada a traficância pelo acusado, declaro a perda do valor apreendido, em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06.

O réu deve permanecer encarcerado, posto que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas que conduziram ao decreto da prisão preventiva.

Com efeito, nesta data o réu foi reconhecida a responsabilidade criminal pela prática do grave crime de tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado.

Outrossim, trata-se de réu reincidente específico, demonstrativo concreto de que pode reiterar na prática delitiva.

Tais circunstâncias revelam a necessidade de se garantir a ordem pública por meio da custódia preventiva.

Não fosse o bastante, fora fixado ao réu o regime fechado para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudescer as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal,

notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada ao sentenciado. Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do *meritum causae*. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

“Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu *incidenter tantum* – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020).

Ante o exposto, não concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade.

Recomende-se-lhe, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intime-se o condenado para o pagamento da multa a ele aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extração de certidão e encaminhamento à Procuradoria do Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, ficando consignado que o pagamento da multa imposta somente poderá ser feito em uma única parcela, ou seja, não será admitido parcelamento e c) proceda-se a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, seguindo-se as instruções baixadas pelo Ministério da Justiça para esse fim.

De acordo com o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais.

PIC.

Ourinhos, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA